

المبحث الرابع: مصادر القانون

بعد أن تطرقنا إلى مفهوم القاعدة القانونية وخصائصها وأنواعها، سننتقل إلى كيفية ظهورها إلى حيز الوجود واكتسابها صفة الإلزام وذلك بدراسة مصادرها ومراحل تشريعها. فوجود القاعدة القانونية هو نتاج تجمع وتفاعل عدة عوامل هي التي تكون جوهر القاعدة القانونية ثم صياغتها الصياغة الفنية في قالب قابل للتطبيق العملي، فالعوامل التي تتكون منها مادة القانون لابد من أن يتوفر لها جانبان جانب الجوهر وجانب الصياغة، ثم بعد ذلك يتوفر لها عنصر الإلزام الذي يخرجها من مجرد قاعدة سلوكية عادية إلى قاعدة قانونية ملزمة.

و انطلاقاً من ذلك يمكن تعريف مصدر القانون بأنه الأصل أو المنبع الذي يستقى منه المشرع جوهر القانون وصفة إلزامه، فكل أصل من الأصول الواقعية أسهم في خلق وتكوين القاعدة القانونية نقول عنه إنه مصدر للقانون ونشير إلي أن كل قاعدة قانونية لابد لها من مصدر مادي تستمد منه مادتها (جسمها) ومصدر رسمي تستمد منه قوتها (روحها).

وبالعودة إلى أية قاعدة قانونية وقراءتها قراءة تحليلية نجدها تتكون من عنصرين الأول يتعلق بتنظيم شأن معين من شؤون الجماعة ويطلق على هذا العنصر (جسم القاعدة القانونية أو مادتها)، والثاني هو الإلزام أو الإيجار الذي تضيفه الدولة على القاعدة القانونية لتكفل احترامها ويطلق على هذا العنصر روح القاعدة القانونية أو رسميتها، فالقاعدة القانونية التي تحرم السرقة تتضمن المنع من السرقة وتتضمن الجزاء المادي الحال الذي من شأنه أن يجعلها ملزمة للأشخاص، ولعل هذا ما جعل بعض الفقه في العصر الحديث يقسم مصادر القانون إلى نوعين فقط مصادر مادية ومصادر رسمية.

ويقصد بالمصدر المادي والذي يطلق عليه أيضاً المصدر الموضوعي مجموع العوامل المختلفة التي تستمد منها القاعدة القانونية مضمون التنظيم الذي تنطوي عليه أو بمعنى آخر فهي تعني مجموع الأصول التي تساهم في تكوين القاعدة القانونية والتي تستمد من الواقع تارة ومن الفكر أو الوسط الطبيعي أو الاجتماعي تارة أخرى، فاستخراج المادة الأولية للقاعدة القانونية يأتي من اجتماع هذه الأصول وتفاعلها والموازنة بينها، وذلك لأن القانون وليد البيئة الاجتماعية.

ولدراسة مصادر القانون سنقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب على النحو التالي:



المطلب الأول: المصادر الموضوعية

ويقصد بها الأصل الذي استمد منه القانون موضوعه وقواعده ويمكن تلخيص المصادر

الموضوعية للقانون الموريتاني فيما يلي:

أولاً: الشريعة الإسلامية:

لقد ظلت الدساتير الموريتانية المتلاحقة كدستور 22 مارس 1959 و20 مايو 1961 تؤكد على أن دين الشعب الموريتاني هو الإسلام أما الميثاق الصادر في 9 فبراير 1985 فقد نص في مقدمته على أن المصدر الوحيد للقانون الموريتاني هو الشريعة الإسلامية، كما نص دستور 1991 في ديباجته على احترام مبادئ الدين الإسلامي المصدر الوحيد للقانون، وإذا نظرنا إلى القوانين نجد أن هناك فعلاً قوانين استمدت مضمونها من الشريعة الإسلامية ونذكر منها مثلاً القانون الجنائي الصادر 1972 والمعدل بالقانون رقم 83/286 بتاريخ 12 مايو 1983 والذي تضمن جزاءات مأخوذة من الكتاب والسنة كالمواد المتعلقة بالقصاص من 280 – 285 والمواد المتعلقة بالدية وهي من 285 – 286 وجلد الزاني المواد 307 – 308 أو رجمه أو قطع يد السارق المادة 351... وكقانون الالتزامات والعقود الموريتاني الصادر 1989 والذي تضمن قواعد ترجع إلى ما هو سائد في الفقه الإسلامي ومنها تنظيم عقد الهبة والتقادم الذي يسقط الدعوى ولا يسقط الحق المادة 269 من ق. ا. ع. م.

وقد نصت المادة 1179 على أنه «يرجع إلى مذهب الإمام مالك في كل ما لم ينص عليه في هذا الأمر القانوني»، وفي هذه المادة دلالة على أن هذا القانون قد استند بوجه عام على الشريعة الإسلامية، كما نجد أيضاً أن المشرع الموريتاني قد استمد نصوص مدونة الأحوال الشخصية من الشريعة الإسلامية.

ثانياً: قوانين بلدان المغرب العربي

لقد تأثر القانون الموريتاني بحكم التاريخ والجغرافيا بقوانين بلدان المغرب العربي وهكذا جاء قانون الالتزامات والعقود الصادر بتاريخ 14/09/1989 مستمداً معظم أحكامه من قانون الالتزامات والعقود المغربي الصادر 1913 في المعاملات مع الاستفادة كثيراً من القانون المدني الفرنسي الذي أخذ عنه بعض الأحكام مع تطويرها إلى ما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. كما تأثر أيضاً قانون الالتزامات والعقود الموريتاني في الكتاب الأول القسم الأول المخصص لأحكام عامة المواد من 1 – 21 بالقانون المدني الجزائري فأخذ عنه أحكاماً تتعلق بنفاذ القانون وتنزاع القوانين.

ثالثاً: التشريع الفرنسي



يلاحظ أن الدساتير الموريتانية بما فيها دستور 1991 كانت تعتمد في كثير من الحالات على الدستور الفرنسي، وعلى العموم فإن القانون الفرنسي يعتبر مصدرا موضوعيا لكثير من التشريعات الموريتانية خاصة فيما يتعلق بتنظيم الدولة وتنظيم الإدارة.

المطلب الثاني: المصدر التاريخي

ويقصد به الأصل الذي يرجع إليه قانون معين والذي يتمثل في أنظمة وأوضاع سابقة فاحتكاك الحضارات وتأثر المجتمع بحكم تاريخه وتطوره الداخلي قد يكون هو منطلق الفكرة القانونية.

فالقانون الروماني مثلا يعتبر مصدرا تاريخيا لكثير من القوانين في أوروبا وانطلاقا من هذا المفهوم فإنه يكون مصادر تاريخية للقانون الموريتاني كل من الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسية وكذلك القانون الروماني.

أ - الشريعة الإسلامية

لقد سبقت الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية تعتبر مصدرا موضوعيا للقانون الموريتاني في مجالات مختلفة غير أن القانون الموريتاني قد استمد قواعده من قوانين بلدان المغرب العربي كما سبق وأن ذكرنا وقوانين بلدان المغرب العربي هذه قد استمدت تلك القواعد من الشريعة الإسلامية وبذلك تكون الشريعة الإسلامية مصدرا موضوعيا لقوانين بلدان المغرب العربي ولكنها في هذه الحالة مصدرا تاريخيا بالنسبة للقانون الموريتاني.

ب - القانون الفرنسي: بالإضافة إلى كون القانون الفرنسي يعتبر مصدرا موضوعيا للقانون الموريتاني فإنه يعتبر أيضا مصدرا تاريخيا له في كثير من الحالات وخاصة الحالات التي كانت فيها قوانين بلدان المغرب العربي مصادر موضوعية للقانون الموريتاني.

ت - القانون الروماني

ويعتبر هذا القانون مصدرا تاريخيا للقانون الموريتاني على الرغم من أن موريتانيا لم تتصل بالحكم الروماني عبر التاريخ وأن القانون الروماني يرجع إلى عهد بعيد والسبب في ذلك يعود إلى القانون الفرنسي الذي أقر مبادئ وقواعد عديدة وضعها رجال القانون في عهد الرومان كما هو الحال مثلا في القاعدة التي تقول "لا عذر لأحد في جهل القانون" والقاعدة الأخرى "العقد شريعة المتعاقدين"، وبما أن القانون الموريتاني أخذ هذه القواعد عن القانون الفرنسي فقد أصبح القانون الروماني مصدرا تاريخيا له.



المطلب الثالث: المصادر الرسمية

وتنقسم المصادر الرسمية إلى مصادر رسمية مباشرة ومصادر رسمية غير مباشرة.

أ – المصادر الرسمية المباشرة

ويمثل المصدر الرسمي المباشر أساسا فيما يسمى بالتشريع وقد أصبح التشريع في العصر الحاضر هو المصدر الرسمي الأصلي للقانون بل إن معظم البلدان ذات الأنظمة المتطورة تعتبر المصدر الأصلي الوحيد وما دونه يعتبر مصادر احتياطية أو تفسيرية كأعمال القضاء وقواعد العدالة.

وقد سعت موريتانيا منذ الاستقلال كغيرها من البلدان النامية إلى جعل التشريع المصدر الرسمي الأساسي لقوانينها ورغم ذلك فإن التشريع ليس هو المصدر الوحيد للقانون الموريتاني فهناك أيضا العرف والشريعة الإسلامية اللذان يشكلان هما الآخران مصادر رسمية للقانون الموريتاني حيث تستمد منهما القواعد القانونية بشكل مباشر ولكن متى وجد التشريع فإنه يعلو على المصادر الأخرى والقاضي ملزم به.

وللتشريع مفاهيم مختلفة فهو مصدر من شرع أي سن القوانين فيقال إن سلطة التشريع ترجع إلى الهيئة المختصة أي للبرلمان أو ما يقوم مقامه، كما يطلق التشريع على مجموعة القوانين الوضعية المكتوبة والسائدة في البلد أو في مجال معين فيقال بهذا المفهوم: التشريع الصادر بعد دستور 1991 ويقال تشريع الشغل أي المعمول به في مجال الشغل كما يطلق أيضا التشريع على النصوص الصادرة في موضوع معين عن السلطة التشريعية المختصة فيقال صدر تشريع أو قانون جديد ينظم التجارة أو النقل البحري.. وهذا هو المفهوم الذي يعبر عنه بلفظ (قانون).

وتجدر الإشارة إلى أن معالجة التشريع كمصدر للقانون تشمل المفهومين الثاني والثالث أي تارة سائر القوانين الوضعية المكتوبة بغض النظر عن الجهة الصادرة عنها وتارة النصوص القانونية الصادرة عن الهيئة التشريعية.

والتشريع بمفهومه الواسع يظهر في الواقع بأشكال ودرجات مختلفة:

ما يصدر عن السلطة التشريعية أي البرلمان أو ما ينوب عنه وهذا هو التشريع أو القانون بمفهومه العادي والمفروض أن التشريع يصدر أصلا عن الهيئة التشريعية دون غيرها وإن كان يمكن في بعض الحالات صدوره عن الشعب مباشرة كما هو الحال في الاستفتاء أو عن السلطة التنفيذية التي تحل محل السلطة التشريعية وتمارس سلطتها وذلك في حالات خاصة تختلف حسب ما إذا كانت السلطة التشريعية موجودة أو غير موجودة ويدخل في هذا المفهوم



النصوص ذات الطابع التشريعي سواء سميت من الناحية الشكلية بقوانين إن صدرت عن البرلمان أو بأوامر قانونية إن صدرت عن هيئات تقوم مقام البرلمان.

يضاف إلى هذا كتشريع فرعي ما يصدر عن السلطة التنظيمية التي تمارس السلطة التنفيذية وتسمى هذه النصوص بالنصوص التنظيمية.

ب – المصادر الرسمية الاحتياطية

وتتمثل في الشريعة الإسلامية والقضاء والعرف

1 – الشريعة الإسلامية: قد يوجد تشريع ينظم وضعاً معيناً ولكنه يتضمن سكوتاً أو تحديداً غير كافٍ في بعض الحالات الأمر الذي يؤدي بالقاضي إلى البحث في مصادر احتياطية يستمد منها الحل المطلوب ويتحقق ذلك على أساس قواعد عامة واردة في الدستور أو في قوانين أساسية فقانون ا.ع.م. مثلاً الصادر سنة 1989 استمد عدداً وافراً من أحكامه من الشريعة الإسلامية سواء كان ذلك صفة مباشرة أو غير مباشرة ولذلك فقد نصت المادة 1179 على أنه «يرجع إلى مذهب الإمام مالك في كل ما لم ينص عليه في هذا الأمر القانوني...» ومعنى هذا أن القاضي في مجال الالتزامات والعقود يطبق أولاً الأمر القانوني فإن لم يجد فيه القاعدة التي يحتاج إليها يرجع إلى الشريعة الإسلامية وخاصة المذهب المالكي كمصدر احتياطي بالنسبة لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني.

2 – العرف: يطلق العرف على العادات الملزمة التي تنظم سلوك الناس في المجتمع ويقوم على عنصرين:

أحدهما مادي والآخر معنوي فالأول يقتضي أن تكون هناك عادة عامة يجري التعامل بها في جميع البلاد أو في جهة أو في إقليم معين.

أما الثاني فيتمثل في اعتقاد الناس أن هذه العادة يجب إتباعها حيث إنها تعتبر في نظرهم من ضروريات السلوك في المجتمع وأنه يترتب الجزاء على مخالفتها.

فالعنصر المعنوي إذا في العرف شبهه بعنصر الإلزام في القاعدة القانونية، والواقع أن إلزامية العرف عادة ما يكون مصدرها القانون سواء كان ذلك عن طريق الإقرار الصريح للعرف أو عن طريق إجازته في المعاملات، فقد وردت إشارات كثيرة إلى العرف في مختلف التشريعات وخاصة في مجال المعاملات المدنية والتجارية فقد أحال مثلاً ق.إ.ع.م. صراحة إلى العرف في حالات عديدة نذكر منها على سبيل المثال م248 التي جاء فيها «كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضاً بكل ملحقات الالتزام الذي يقرره القانون أو العرف أو الإنصاف وفقاً لما تقتضيه طبيعته».

ومن نافلة القول إن العرف لا يمكن أن يخالف التشريع الوضعي ولا الشرع الإسلامي إذا كان مصدراً للقانون (الشريعة).

3 - القضاء: من المبادئ المعروفة في مختلف الأنظمة أن القاضي يطبق القانون ولا يشرع فهو يفصل في القضايا المطروحة على أساس القواعد القانونية التي يلتزم بها من دون تقديرها أما في القانون الإنجليزي فمن المعروف أن القاضي يرجع بالدرجة الأولى إلى الأحكام القضائية السابقة فيستند إليها بالفصل في القضية المطروحة عليه. وموريتانيا سواء رجعنا إلى ما هو معمول به في الفقه الإسلامي أو إلى ما أخذته عن القانون الفرنسي فإنها تعمل بالمبدأ الذي مؤداه أن القاضي يطبق القانون وربما يجتهد في تفسيره ولكنه لا ينشئ القاعدة القانونية.

المطلب الرابع: المصادر التفسيرية

وستنطلق فقط إلى أهم هذه المصادر على النحو التالي:

أولاً: القضاء

وتتمثل مهمة القضاء في فض النزاعات بين الناس بتطبيق القانون المعمول به وهو بذلك يلزم الأفراد والمؤسسات بمراعاة القانون عن طريق توقيع الجزاء على من يخالفه وهو بذلك يضمن تحقيق ما يرمي إليه القانون من بسط العدالة وحماية النظام الاجتماعي واحترام حقوق الجميع. وتحقيق هذه المهمة المناطة بالقضاء تتطلب منه تمتعه بالحرية الكافية المجردة من الخضوع للأفراد والضغوط من أية جهة كانت ولذلك فإن القاضي ليس بموظف يخضع لأوامر رئيسه في الإدارة ولكنه يمارس وظيفته باستقلال في مواجهة الجميع وهذا ما نصت عليه الدساتير المتعاقبة في موريتانيا كدستور 59 - 61 - 91.

وقد نصت جميع هذه الدساتير على أن التنظيم العام للدولة يقوم على الفصل بين السلطات الثلاثة (التشريعية، التنفيذية، القضائية).

ثانياً: الفقه:

ويقصد به أعمال الفقه المختلفة من شرح وتفسير ونقد للتشريع كما يقصد به أيضاً النظريات والأنظمة القانونية المقارنة.

فمهمته التعريف بالفكر القانوني ونشره وتطويره فكل تلك المهام منوطة بالفقهاء وقد تطور دور الفقيه بالعصر الحاضر حيث أصبح المفسر للقانون وذلك بإعطائه المفاهيم الدقيقة للنص القانوني دون الوقوف عند المعنى الشكلي أو الأصلي للنص، وهو لا يقتصر على تحليل النص وإنما يتعدى ذلك إلى تقدير القاعدة الواردة في النص والتعليق عليها واقتراح تعديل لها أو تكميل لها أو باستبدالها بقاعدة أخرى حسب الحالات، وعلى الرغم من أن الفقيه لا يشرع ورأيه غير ملزم للقاضي إلا أنه رغم ذلك يبقى مصدراً تفسيرياً هاماً لا يستغنى عنه القاضي فهذا الأخير

عند تفسيره للقاعدة القانونية يرجع أولاً إلى تفسير الفقه فيستعين به للوصول إلى موقفه النهائي. والنسبة للحالة القانونية التي يواجهها، ومن النادر جداً أن يهمل القاضي المواضع الفقهية السائدة في عصره.

